

1501168-64.2021.8.26.0571

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Teixeira Salviano da Rocha

Comarca: Tatuí

Foro: Foro de Tatuí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... com o motoqueiro e forjaram seu trafico. Quando era menor os guardas o pegaram vendendo droga e como ele saiu rápido, eles começaram a forjar para ele em relação ao tráfico. Teve umas 6, 7 passagens na vara da infância. Hoje está com 23. Após os 18, esse guardas diziam que o fariam ir preso. Ficou preso dos 18 aos 22 anos. Lhe forjaram porções de maconha. Não estava com ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tatuí/ Foro de Tatuí

1ª Vara Criminal

Avenida Virgílio Montezzo Filho, 2009, Nova Tatuí - CEP 18278-440, Fone: (15) 3251-4013, Tatuí-SP - E-mail: tatui1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501168-64.2021.8.26.0571

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2234839/2021 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 19910266 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 1972/21/609 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI, 2234839 - DEL.POL.PLANTÃO TATUI

Réu:

VINICIUS FELIPE BRITO DE ANDRADE

Artigo da Denúncia:

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD c/c Art. 61 "caput", II, "j" do(a) CP c/c Art. 40

"caput", III do(a) SISNAD(Denúncia)

Data da Audiência:

11/02/2022

Réu Preso

Em 11 de fevereiro de 2022, às 13:30h, por meio da plataforma Microsoft Teams, onde virtualmente se encontrava a Exma. DR.^a MARIANA TEIXEIRA SALVIANO DA ROCHA, MM^a Juíza de Direito Titular, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeado, pela MM^a Juíza foi determinado que se abrisse a presente teleaudiência, o que foi feito, com as formalidades legais. Apregoadas as partes, virtualmente se achavam: a representante do Ministério Público, na pessoa do DRA. FABIANA MARIA NOVAES CANATELLI RODRIGUES, DDa. Promotora de Justiça da Comarca de Tatuí, o réu VINICIUS FELIPE BRITO DE ANDRADE, bem como o seu Defensor Técnico, DR. Rogerio Aparecido da Costa OAB 321540/SP. Ainda, encontravam-se na sala de reunião virtual as testemunhas Eduardo Leopoldo Ambold (GCM) e Daniel Adriano Vieira (GCM). INICIADOS OS TRABALHOS, com a concordância das partes na realização do ato de forma virtual, foi dada a oportunidade de o acusado se entrevistar reservadamente com o seu Defensor. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas acima mencionadas, passando-se ao interrogatório do réu. As perguntas foram inicialmente formuladas pela MM^a Juíza de Direito, eis que as partes não solicitaram que as inquiries fossem por elas iniciadas. Em razão da suspensão dos trabalhos presenciais nos prédios do Tribunal

de Justiça de São Paulo, como forma de prevenção e contenção do Covid-19 (Provimento nº 2545/2020 do Conselho Superior da Magistratura), a presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio audiovisual, através da plataforma Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG nº 284/2020, com o armazenamento dos arquivos digitais conforme determinado no Comunicado CG nº 1350/2020. Por fim, devido à instabilidade na rede de internet, cada oitiva será gravada em arquivo individual, identificados, para que não haja o risco de perda de a gravação, acaso toda a solenidade seja gravada em apenas um arquivo. Na sequência, pela MM. Juíza de Direito foi dito: Não havendo mais provas a serem produzidas ou colhidas, dou por encerrada a instrução e concedo a palavra às partes, para os debates. Os debates orais foram gravados em audiovisual, na forma acima mencionada. Ato contínuo, pela MM. Juíza de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA: "Vistos. O réu VINICIUS FELIPE BRITO DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, eis que, em 27 de agosto de 2021, por volta das 17h45, na rua Antônio Orlando Salmasi, altura do nº 486, nesta cidade e Comarca de Tatui, nas imediações de estabelecimento de ensino, trazia consigo, para entrega de qualquer forma ao consumo de terceiros, 14 porções de "crack", substância composta por cocaína, com peso bruto aproximado de 2,92 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo consta da exordial, o acusado praticava o tráfico na via pública, sendo que trazia as drogas em mãos, de forma a facilitar as entregas aos interessados. Guardas Civis Municipais efetuavam patrulhamento de rotina - em local conhecido pela intensa mercancia ilícita - quando receberam a informação de que VINICIUS estava traficando, sendo indicado seu nome, bem como as características físicas e as vestimentas. Os agentes públicos avistaram VINICIUS entregando algo para um motociclista. Ao notarem a aproximação da viatura, ambos empreenderam fuga. O acusado, enquanto tentava escapar, jogou as porções de drogas ao chão. VINICIUS foi detido e, na revista pessoal, foram encontrados R\$ 115,00 e o aparelho de telefonia celular. Em seguida, os Guardas localizaram as drogas dispensadas, tratando-se de 14 porções de "crack". O réu foi notificado (fls. 104) e apresentou Defesa Preliminar (fls. 125/126). Assim, por decisão proferida no dia 14 de janeiro de 2022, foi recebida a denúncia (fls. 129/131). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, ultimando-se com o interrogatório do réu, tudo gravado em audiovisual. Em sede de alegações finais, o Órgão Ministerial postulou pela condenação do acusado nos exatos termos da Denúncia, enquanto a Defesa Técnica, de outro lado, pugnou pela absolvição do acusado, sustentando insuficiência probatória, bem como, subsidiariamente, a desclassificação delitiva e, finalmente, em caso de condenação, pela incidência de todas os benefícios legais cabíveis a incidir em dosimetria da pena e na fixação do regime prisional inicial. Folha de antecedentes a fls. 23/26, bem como Certidões a fls. 27/30. É o relatório do necessário. Fundamento e Decido. Pois bem, o pedido acusatório comporta parcial procedência. De fato, deve ser afastada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, pelas razões que passo a expor. A despeito da majorante em questão ter natureza objetiva e, portanto, dispensar a intenção do traficante de captar sua clientela junto aos frequentadores dos locais elencados no dispositivo legal supra citado, tem-se que, para não gerar responsabilidade penal objetiva, exige-se que haja concentração de pessoas nas proximidades e adjacências daquele lugar para justificar a incidência da causa de aumento especial em tela. Ora, a ratio da norma visa exasperar a pena de pessoa que se aproveita da aglomeração de pessoas nas proximidades daquele local, facilitando a ocultação e evasão do traficante. In casu, como os fatos se deram por volta das 17h45, e o estabelecimento de ensino apontado a fls. 85/86 tem horário de funcionamento diurno e vespertino, até às 17h00 (pesquisa pelo google aponta fechamento às 17 horas) estando, portanto, fechado, não havia concentração de pessoas a justificar a incidência da causa de aumento em questão. A propósito, assim se posiciona a jurisprudência do C. STJ: RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA

DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância. 3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela. 4. Recurso especial improvido. (REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018). Ademais em pesquisa pelo google maps, o percurso a ser realizado a pé ou de carro de um ponto a outro, aponta a distancia de 1 km, portanto, não há que ser considerado como imediações do local dos fatos. Anoto que a distancia apontada no croqui de fls. 89 é traçada em linha reta e não ao corresponde ao efetivo percurso de um ponto a outro. No mais, a pretensão acusatória merece ser acolhida, uma vez que a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do delito de tráfico de entorpecentes, que se configurou consumado, não havendo dúvidas quanto à autoria, bem patenteada a tipicidade da conduta do crime descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. De fato, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/04), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 05/06), pelo auto de constatação preliminar (fls. 07/08), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 80/82) e, finalmente, pela contundente prova oral produzida. A autoria é igualmente evidente e clara. Vejamos: O réu, em solo policial (fls. 11), afirmou que, na data dos fatos, não estava traficando. Assim, afirmou que estava indo até a residência de sua avó, local este onde reside, quando percebeu a presença da GCM. Como tinha uma ponta de maconha nas mãos, correu. Afirmou que, mesmo após ouvir para parar, continuou correndo, sendo, porém, abordado. Destacou que, durante a fuga se livrou da maconha, e que a droga era para seu consumo pessoal. Negou a posse das drogas aqui apresentadas, no caso, 14 (quatorze) pedras de crack, afirmando que não são suas e não estava vendendo. Indagado sobre motociclista, afirmou que, enquanto caminhava, foi abordado por uma pessoa desconhecida em uma motocicleta lhe solicitando a venda de drogas, porém, não vende tais substâncias. Em juízo, disse que estava na rua Antonio Orlando Salmasi, pois mora na rua de cima e sua mãe mora na rua de trás. Dias antes tinha sido abordado pelos GCMs que foram ouvidos nesta data e eles disseram que ele não passaria o natal solto. Sempre foi preso por esses mesmos guardas. No dia dos fatos, o motociclista realmente o abordou e perguntou sobre droga e ele disse que não tinha. Esse dinheiro foi sua mãe que lhe deu para entregar para sua filha. Sua mãe tinha ido trabalhar nesse dia. Esses guardas o viram conversando com o motoqueiro e forjaram seu trafico. Quando era menor os guardas o pegaram vendendo droga e como ele saiu rápido, eles começaram a forjar para ele em relação ao tráfico. Teve umas 6, 7 passagens na vara da infância.

Hoje está com 23. Após os 18, esse guardas diziam que o fariam ir preso. Ficou preso dos 18 aos 22 anos. Lhe forjaram porções de maconha. Não estava com nenhuma porção de crack e é usuário de maconha. Estava tentando conseguir emprego e estava de regime aberto. Tem uma filha de 4 anos. Analisando a autodefesa do acusado - colhida com máxima observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - é possível verificar que o réu negou a prática do tráfico de drogas, o que, contudo, não encontrou respaldo na prova produzida nos autos. Bem verificado pela promotora de justiça nesta oportunidade, que nas outras duas condenações por trafico ostentadas pelo réu, as testemunhas ouvidas não correspondem as testemunhas neste autos, assim, cai por terra a alegação do réu de que é perseguido pelos

guardas municipais ouvidos nesta data e que eles teriam forjado todas as suas prisões. De fato, o Guarda Civil Municipal Daniel Adriano Vieira, em sede policial (fls. 09), relatou que, na data dos fatos, juntamente com seu parceiro, estavam realizando patrulhamento de rotina por bairro conhecido nesta cidade de Tatuí como muito utilizado ao comércio ilícito de drogas. Naquela ocasião, um popular "denunciou" o crime de tráfico de drogas ocorrendo na rua Orlando Salmasi, indicando, ainda, o nome do agente, tratando-se de "Vinicius". Também indicou as roupas que ele usava e as características físicas. Imediatamente a equipe diligenciou até o local indicado, onde claramente foi observado que uma pessoa com as características indicadas entregava algo para outra, esta segunda em uma motocicleta. Porém, os agentes perceberam a presença da viatura e tentaram fugir, o que foi consumado por aquele que estava na motocicleta. Já o segundo agente foi efetivamente abordado e identificado como VINICIUS FELIPE BRITO DE ANDRADE. Esclareceu que, durante fuga, o acusado dispensou algo ao chão, sendo posteriormente constatado tratar-se de 14 (quatorze) pedras de substância aparentando ser crack. Em sua posse também foi localizada a quantia de R\$ 115,00 (cento e quinze reais) e um aparelho de telefonia celular. Instado, espontaneamente confessou o delito de tráfico, expondo até os valores das substâncias que vendia, sendo R\$ 10,00 (dez reais), cada porção (pedra de crack). Acrescentou que populares tentaram "resgatar" no momento da prisão, porém, com a chegada do apoio, todos deixaram rapidamente o local, não sendo possível conduzir qualquer outra pessoa. Em juízo, a testemunha disse que um morador narrou o tráfico de drogas, deu o nome do indivíduo Vinicius que estava na biqueira em frente a vielinha e deu a descrição da roupa. O réu Vinicius já era conhecido dos meios policiais. Foram até o local, localizaram o réu que negociava, conversava com um motociclista e visualizou o réu entregar algo para o motociclista. Com a aproximação o motoqueiro conseguiu fugir e o réu correu, sendo que no percurso colocou a mão no bolso e jogou algo. Em certo momento da perseguição o réu desistiu da fuga e se entregou. Na mão do réu havia dez reais e em seu bolso havia cento e cinco reais e o celular. Verificaram que o réu dispensou a droga. Populares tentaram tumultuar o local ao verem que o réu estava sendo informado. Tinham várias informações de que o réu estava vendendo drogas no local novamente. O réu disse que era usuário de maconha, não aparentava estar sob efeito da droga e com ele não foi encontrado qualquer apetrecho para o uso da droga. Populares tumultuavam com a intenção de libertar o réu e algum deles foram reconhecidos como "vapores", vendedores de droga. O local que o réu estava era a biqueira do bairro, o bairro é muito grande. É comum ter denúncias, pois as pessoas temem por seus filhos serem alvo do tráfico. O denunciante tinha mais ou menos sua estatura, branco, uma idade de 45 anos. Foram vapores, olheiros, gerentes do tráfico que tentaram resgatar o réu e causaram um tumulto. Visualizou o réu dispensando a droga e ficou o encalço do réu durante a fuga. O local dos fatos dista uma quadra e meia da escola. Há creche, pré escola, ensino fundamental. Acredita que a creche estava aberta. Convergindo em mesmo sentido, o também Guarda Civil Municipal Eduardo Leopoldo Ambold, em sede policial (fls. 10), corroborou integralmente a versão de seu colega de trabalho. Em juízo, a testemunha disse que estavam em patrulhamento na entrada do bairro quando foram abordados por um morador que disse ter visto o réu vendendo entorpecente, que vestia uma blusa preta com detalhes em azul e apontou o local. Foram ao local apontado e visualizaram o réu (já conhecido por outras ocorrências), sendo que o réu entregava algo a um indivíduo. Quando conseguiram se aproximar o réu jogou algo ao solo e em abordagem foi encontrado em seu poder o valor de R\$115,00 e um celular e verificou-se que aquilo que havia dispensado se tratava de 14 porções de crack. Com o réu não foi encontrado nenhum apetrecho para o consumo da droga. Há uma escola próxima ao local e salvo engano também há uma creche nas proximidades. Na mão do réu estava uma nota de dez reais, indicando que ele havia acabado de receber este valor. O restante do dinheiro estava no bolso. Viu o acusado jogar a droga ao chão. No momento que o réu saiu correndo já pediram apoio, sendo que primeiro chegou o canil ao local. Houve um tumulto no local e por isso foi solicitado o apoio. O réu dizia: "perdi, perdi", na delegacia não sabe o que ele falou. Não sabe dizer se a escola estava funcionando por causa da pandemia. A escola dista uns dois

quarteirões e meio do local dos fatos. Em relação à validade e à eficácia probatória dos depoimentos dos agentes de segurança, impende destacar que nossos tribunais vêm rechaçando qualquer análise discriminatória quanto aos seus testemunhos, atribuindo-lhes valores idênticos às versões judiciais de demais testemunhas. Até mesmo porque, in casu, inexistem motivos para desqualificar os depoimentos dos guardas, pois não há provas ou indícios nos autos indicando que estes pretendiam incriminar injustamente o réu ou faltar com a verdade. Por tais razões, seus testemunhos merecem normal credibilidade e valor probatório. Neste sentido: Furto Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes dos guardas municipais, da testemunha e na confissão policial e judicial do réu Validade Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos, principalmente se o acusado, ao ser interrogado perante a autoridade policial e em Juízo, tudo admitiu, Nos crimes de furto a palavra dos ofendidos e das testemunhas é crucial à elucidação dos fatos. No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos agentes públicos, os tribunais têm ainda deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de agente público não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (TJ-SP - APL: 00038815620128260198 SP 0003881-56.2012.8.26.0198, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 20/03/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/03/2014) (grifos aditados). Examinando o arcabouço probatório emergentes dos autos, nota-se a cabal comprovação de perpetração do crime de tráfico de entorpecentes. Ora, é inequívoco que o acusado trazia consigo e guardava substâncias entorpecentes, conforme: 1) os coerentes e insuspeitos depoimentos dos Agentes Públicos, que narraram verossimilmente, a apreensão das drogas onde o acusado as dispensou; e 2) o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 80/82), o qual atestou que a substância apreendida era entorpecente. Igualmente indisfarçável é a finalidade mercantil da droga, a despeito da não flagrância de ato de mercancia de narcóticos. Deveras, a infração penal de tráfico de entorpecentes é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando, portanto, que o agente pratique qualquer um dos verbos nucleares contidos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com a intenção de traficar entorpecentes, para que o delito previsto no dispositivo legal retro mencionado reste configurado. Estabelecida esta premissa e escorada na previsão legal contemplada no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, verifico que as circunstâncias fáticas estão a evidenciar o dolo do réu de traficar a droga apreendida. Com efeito, tem-se: 1) a quantidade de narcóticos apreendidos; 2) sua forma de embalagem, em pequenas frações, forma de acondicionamento própria para a venda "a varejo" de entorpecentes; 3) a conduta do acusado, o qual, ao avistar a viatura, apresentou comportamento suspeito, consistente em dispensar drogas e tentar fugir; 4) a não apreensão de qualquer instrumento ou apetrecho utilizado para o consumo das drogas; 5) a localização do acusado em local notoriamente conhecido pelo comércio de drogas e 6) a exata correspondência do local e das características do réu, inclusive sua identificação nominal, com o do traficante delatado anonimamente. Válido mencionar que as fundamentações acima expostas foram utilizadas no precioso voto da lavra do Des. Rel. Penteado Navarro nos autos da Apelação 0005659-54.2010.8.26.0320, TJSP, 9ª Câmara de Direito Criminal, d.j. 24/11/2011, r. 28/11/2011, o qual transcrevo em parte: "Outrossim, havendo conhecimento de que o local onde os apelantes se encontravam era "ponto de tráfico" e, ainda, levando-se em consideração a quantidade da droga apreendida (8,9 g de "cocaína" em pedra e 3,2 g em pó), bem como a sua forma de acondicionamento (27 invólucros de plástico contendo pedrinhas de cor amarela, envoltos por plástico, sendo 4 na cor azul e 23 na cor branca, além de outros 27 invólucros

da mesma substância e 11 invólucros tipo "eppendorf" de plástico incolor com tampa, contendo pó de cor amarela - fls. 76/79), não resta qualquer dúvida de que os apelantes praticavam o comércio de drogas no local. Note-se que uma das principais circunstâncias indicadoras de tráfico é a quantidade de tóxico. E, para

mim, tal mensuração deve partir da overdose (dose insuportável ou excessiva para alguém). Segundo a literatura médica, a reação letal ou não letal da “cocaína” em usuários depende de variados aspectos. Doses consideradas pequenas, cerca de 0,02g, podem ser suficientes para esse efeito (cf. Delton Croce e Delton Croce Júnior, Manual de Medicina Legal, 5ª ed., Saraiva, 2004, pág. 636). Logo, aprendidas 3,2 gramas da droga em pó, teremos cerca de 160 doses letais (excessivas ou insuportáveis) ao usuário. Até porque o uso continuado de “cocaína” provoca o “enfraquecimento das funções psíquicas em geral, cansaço, irritabilidade, inquietação e insatisfação” (cf. Edevaldo Alves da Silva, Tóxicos, 1ª ed., Bushatsky, 1979, pág. 82). Destarte, a conduta inserida em qualquer dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei de Drogas, implica em tráfico, onde o dolo é sempre genérico. Daí segue não ser indispensável para o caso a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga ou de associação para tanto, bastando o conjunto de indícios e presunções (circunstâncias ligadas ao fato probando) que envolve o agente acusado. Sem dúvida, o juiz não pode desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas. A experiência comum é aquele conhecimento adquirido pela prática e pela observação do cotidiano. Nesse sentido há manifestações da doutrina e da jurisprudência (cf. José Frederico Marques, Elementos de Direito Processual Penal, 1ª ed., Bookseller, 1997, vol. II, § 95, item 525, pág. 346, nota 9; Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 10ª ed., 2011, art. 239, item 4, págs. 544-5; Guilherme Madeira Dezem, Da Prova Penal, 1ª ed., Millennium, 2008, cap. IV, item, 12.2, págs. 272; STF, 2ª T., HC 70.344/RJ, rel. Min. Paulo Brossard, RTJ, 149/521; STJ, 6ª T., HC 15.736/MG, rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU, 23/04/01, pág. 189; LexSTF, 182/356; RT, 673/357, 711/378, 728/543, 744/602, 748/599, 758/583, 769/602 e 854/654: RJDTACrimSP, 5/167, 6/137, 7/105, 16/133, 25/324 e 28/209). Para Fernando de Almeida Pedroso, “em sede de tráfico de substância entorpecente, constituem prova indiciária do malsinado e vil comércio, exemplificativamente, a quantidade apreendida de estupefacientes, denotando sua incompatibilidade com a destinação para o próprio uso; a forma de fragmentação e acondicionamento do tóxico, confeccionado em diversas embalagens ou unidades distintas e individuais, indicando o propósito de venda a varejo” (cf. Prova Penal, 2ª ed., RT, 2004, item 5, pág. 96) Nessa linha de entendimento, é a jurisprudência atualmente majoritária (cf., *verbigratia*, RTJ, 149/521; RSTJ, 142/454 e 169/499; RJTJERGS, 177/57; LexJTJ, 165/334, 170/288, 174/333, 180/284, 186/305, 205/314, 208/272 e 277/523; RT, 537/335, 675/406, 714/357, 718/394, 727/478, 729/542, 737/684, 739/639, 740/634, 747/642, 776/663, 779/554, 789/536, 793/576, 793/727, 800/597, 801/606, 807/597, 832/588. Portanto, provado que se faz presente a elementar do tipo substância entorpecente (laudo de exame químico-toxicológico a fls. 80/82) e demonstrado que o réu incorreu em verbo nuclear contido no artigo 33, caput, da Lei 11343/06 – trazer consigo–, fazendo-o com a inegável e nítida intenção de traficar drogas (elemento subjetivo do tipo), resta caracterizada a infração penal indicada no dispositivo legal retro mencionado. Certo, portanto, que o réu perpetrou o crime de tráfico de entorpecentes, não incorrendo em hipóteses de exclusão da ilicitude e/ou da culpabilidade, emerge-se o *jus puniendi*, razão pela qual passo a dosimetria da pena a ser lhe imposta. Observando as diretrizes gerais, traçadas no artigo 59 do Código Penal, e as específicas, dispostas no artigo 42 da Lei 11.343/2006, verifico que as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis. De fato, observo que o acusado ostenta duas condenações criminais definitivas, de modo que utilizarei uma delas (Proc. 0000288-88.2017.8.26.0571 – fls. 27) como Maus antecedentes, e a outra como agravante de reincidência, sem que se incorra em *bis in idem*. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do E. TJSP: “é plenamente viável o rateio das duas condenações definitivas do réu João entre antecedentes e reincidência, sem incidir em *bis in idem*, permitindo a correta individualização de sua pena, de acordo com todas as circunstâncias do caso concreto.” (TJSP; Apelação Criminal 1500174-20.2021.8.26.0544; Relator (a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Franco da Rocha - Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021). De igual modo, entende o C. STJ (“É firme o entendimento desta Corte Superior de que, em se

tratando de agente que ostenta mais de uma condenação definitiva anterior, não configura bis in idem nem ofensa à Súmula 241 do STJ a utilização de anotações criminais distintas na primeira e segunda etapa da dosimetria para reconhecer, respectivamente, os maus antecedentes e a agravante de reincidência. Precedentes" - HC 304.411/RJ, j. 03/05/2018). Por tal razão, fixo sua pena-base acima do mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Em segunda fase, presente a agravante de reincidência, que aliás, é específica (Proc. nº 0001093-41.2017.8.26.0571, fls. 27/28), agravo sua pena na fração de 1/5, gerando a reprimenda legal de 07 (sete) anos de reclusão e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, a qual torno definitiva, à mingua de demais causas modificadoras da pena. Cabe ressaltar a inaplicabilidade da agravante do estado de calamidade pública. Ora, não há provas de que o acusado se valeu das fragilidades proporcionadas pela situação calamitosa ou que agravou esse estado. Assim, imperioso o afastamento da agravante postulada pelo Parquet. Aliás, assim se posiciona a jurisprudência: "Contudo, entendo que a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, relativa ao estado de calamidade pública, deve ter na sua incidência relação com o contexto do delito e a desproteção do bem jurídico tutelado pelo tipo penal. No entanto, no caso em apreço, entendo não comprovada relação direta entre o cometimento do delito e a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus (declarada pelo Decreto Legislativo nº 6, de 2020), de modo que o reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em razão do crime ter sido praticado durante estado de calamidade pública, deve ser afastado. Note-se que não há qualquer evidência nos autos de que o estado de calamidade tenha facilitado a ação criminosa, de que o apelante tenha se aproveitado dessa situação excepcional para perpetrar o delito ou, ainda, de que o crime tenha sido mais grave por ter ocorrido durante a pandemia" (TJSP; Apelação Criminal 1501673-18.2020.8.26.0530; Relator (a): Osni Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 é inaplicável ao caso sub judice. De fato, a incidência dessa benesse legal reclama a presença simultânea de 04 requisitos subjetivos, a saber, primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades delitivas e não integração a organização criminosa. In casu, tratando-se de réu reincidente e de maus antecedentes, resta inviabilizada a concessão da benesse em questão. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal e, com fulcro no artigo 33, § 3º, c.c. art. 59, III, ambos do Código Penal, determino que o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, dada a reincidência, que aliás é específica, e maus antecedentes do acusado, que reclama a fixação de regime prisional mais severo para a contenção do ímpeto criminoso do réu. As mesmas motivações acima expostas impedem a concessão dos benefícios do art. 44 do Código Penal. Por derradeiro, deixo de aplicar a regra da progressão antecipada (art. 387, §2º, do CPP), posto que a concessão desta medida dependa da análise de condições não exclusivamente objetivas, tal como o bom comportamento carcerário. Em assim sendo, não havendo nos autos informações sobre o cumprimento da pena, a viabilidade de concessão desta benesse restou prejudicada. Neste diapasão é o entendimento do E. TJSP. Vejamos: "No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei nº 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena". (TJSP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n. 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. ALBERTO MARIZ DE OLIVEIRA, julgado em 04.06.2013). Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE Procedente a pretensão punitiva para, afastando a causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Drogas, condenar o réu VINICIUS FELIPE BRITO DE ANDRADE, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, com valor unitário no mínimo legal. Indefiro o Apelo em Liberdade ao réu, na medida em que permanecem inalteradas as razões que determinaram a segregação cautelar do acusado. E mais, considerando a reincidência, que aliás é específica, e maus antecedentes do

acusado, evidente que, acaso solto, tornará a delinquir, motivo pelo qual sua prisão preventiva é

absolutamente necessária para garantir a ordem pública. E não se venha alegar a situação de calamidade pública decorrente da doença COVID 19, gerada pela infecção do vírus sars-cov-2 ("coronavírus"). Trata-se de tema que reclama prudência judicial no exame das medidas cautelares pessoais, em especial, as prisões preventivas e temporárias. Isso porque, se é fato que as aglomerações de pessoas podem acelerar o contágio da doença e sua disseminação, também é verdade que a libertação indiscriminada dos presos, além de implicar indiscutível prejuízo à manutenção da segurança pública e da aplicação da lei penal (já que há o indiscutível risco de, em tese, praticar novos delitos ou por-se em fuga), também poderá propiciar, por esse fluxo acentuado de pessoas, maior transmissão da enfermidade. É dizer, pode ser que o preso, agora libertado, já esteja infectado, mas em quadro assintomático (o que, segundo dados científicos, pode demorar até 2 semanas ou nem mesmo se manifestar), o que proporcionará a infecção de seus familiares e outras pessoas com quem tiver contato. Outrossim, em estabelecimentos prisionais, onde o acesso de pessoas é controlado e, por ora, proibido, há menor probabilidade ser contaminado do que, em liberdade, saindo as ruas, onde não se tem controle sob a mobilidade dos cidadãos. Dito de outro modo, se a intenção é preservar a saúde do preso, é possível que, em liberdade, por não haver restrição e/ou controle de sua mobilidade, tenha maior possibilidade de contrair a doença do que preso, onde o acesso de pessoas é restrito e, por ora, proibido. O que se quer dizer, em síntese, é que a alegação de pandemia não conduz, invariavelmente, a soltura do preso. Devem ser analisadas outras peculiaridades do caso concreto. In casu, os elementos acima apontados denotam que é o caso de manutenção da prisão preventiva, o que não se altera com a situação de calamidade pública gerada pelo coronavírus. Até porque não se tem notícia de preso infectado na unidade prisional do acusado, que esse se encontra enfermo, tampouco que integra grupo de risco. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido. Oportunamente, expeça-se guia de recolhimento e arquivem-se os autos. Isento o acusado do pagamento das custas processuais, concedendo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita. Nos termos do Provimento da CG nº 11/2015, com o trânsito em julgado, calcule-se o valor total de pena de multa. Após, intime-se o réu para que efetue o pagamento no prazo de 10 (dez) dias. Sem prejuízo, considerando que o entorpecente apreendido já foi periciado, destrua-se a droga na forma da lei. Como efeito da condenação, por força da regra do art.91, II, "b", do Código Penal, c.c. art.63, da Lei nº 11.343/06, determino a perda do bem apreendido (R\$ 115,00 em dinheiro - fls. 84), pois comprovada sua proveniência criminoso, em favor da união, apropriados ao Funad (§1º do referido art.63). Quanto aos demais bens apreendidos, acaso transitado em julgado e decorrido o prazo de 90 dias sem que se reclame a liberação dos demais objetos, destrua-se esses na forma do que preceitua os arts. 123 e 124, ambos do CPP. Pelo Defensor do réu e pelo réu foi manifestado o interesse em interpor recurso. Pela MM. Juíza de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo réu, saindo o Defensor, desde já, intimado a apresentar razões de recurso, no prazo de 08 (oito) dias, sob pena de destituição e nomeação de novo Defensor. Após apresentadas as razões, expeça-se a competente certidão de honorários (fls. 121). Com a vinda das contrarrazões remetam-se os autos à superior instância com as cautelas de praxe". Com o trânsito em julgado da condenação criminal, lance-se o nome do(a) réu no rol dos culpados. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados. Registre-se. ENCERRADOS OS TRABALHOS, e nada mais havendo, foi lavrado e assinado o presente termo digitalmente pela MM. Juíza, dispensando-se a assinatura dos demais envolvidos, por se tratar de processo digital - Sistema SAJ, com a concordância das partes, nos termos do art. 25, caput, da Resolução nº 185/13 do E. Conselho Nacional de Justiça. NADA MAIS. Eu, Mario Henrique Machado, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA